

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7330/2540

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาว มาลี วิสราญกุล

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 17, มาตรา 59

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 212, มาตรา 225

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง, มาตรา 40 (1), มาตรา 42, มาตรา 66, มาตรา 66 ทวิ, มาตรา 67

จำเลยจัดให้มีการก่อสร้างอาคารที่ผิดรายการที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น ซึ่งขัดต่อมาตรา 31 วรรคหนึ่ง และแม้จำเลยจะเข้าใจโดยสุจริตหรือสำคัญผิดว่า ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 5 ชั้นก็ตาม อาคารที่จำเลยก่อสร้างก็ยังเป็นอาคารที่ผิดรายการที่ได้รับอนุญาตโดยไม่ต้องพิจารณาถึงเจตนาของผู้ดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด

แม้จำเลยจะมีใช้ผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ผิดรายการที่ได้รับอนุญาตแต่ได้รับโอนมาเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าว ก็ไม่สามารถทำให้จำเลยมีอำนาจดำเนินการก่อสร้างให้ผิดรายการที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้อีก และจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวให้พ้นจากภาระหน้าที่ในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนอาคารที่ผิดรายการที่ได้รับอนุญาตนั้นหาได้ไม่

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้จำเลยระงับการก่อสร้างอาคารและได้มีคำสั่งให้จำเลยรื้อถอนอาคารเพราะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

อันเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนและถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่จำเลยผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารได้ฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ระงับการก่อสร้างอาคารและให้รื้อถอนอาคารด้วยการก่อสร้างอาคารต่อไปและงัดเว้นไม่ยอมรื้อถอนอาคาร ย่อมถือได้ว่าจำเลยกระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันจำเลยประสงค์ต่อผลซึ่งเป็นการกระทำโดยเจตนา ต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้จำเลยดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ซึ่งจำเลยต้องรื้อถอนอาคารบางส่วนก็ตาม แต่จำเลยมิได้ดำเนินการรื้อถอน และยังคงฝ่าฝืนต่อไป กรณีเช่นนี้หาทำให้จำเลยพ้นจากการเป็นผู้กระทำผิดไม่

จำเลยจัดให้มีการก่อสร้างอาคารที่ผิดจากรายการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มาตรา 31 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดกรรมหนึ่งแล้ว ส่วนความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารเกิดขึ้นเมื่อจำเลยทราบคำสั่งแล้วกระทำการก่อสร้างต่อไปเป็นความผิดอีกกรรมหนึ่ง และความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเกิดขึ้นเมื่อจำเลยทราบคำสั่งแล้วงัดเว้นไม่ยอมรื้อถอนอาคารภายในเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดก็เป็นความผิดอีกกรรมหนึ่ง

แม้การปรับบทกฎหมายลงโทษจำเลย คู่ความมิได้ฎีกาขึ้นมาแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยและเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องได้

เมื่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง และมาตรา 66 ทวิ ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความไว้ จึงต้องนำอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาปรับใช้ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17

ความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารเริ่มแต่วันที่จำเลยได้รับคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารแล้วไม่ปฏิบัติตามคำสั่งติดต่อกันไปจนถึงวันที่จำเลยดำเนินการก่อสร้างอาคารเสร็จ อายุความฟ้องร้องย่อมนับถัดจากวันที่จำเลยดำเนินการก่อสร้างอาคารเสร็จ กรณีหาใช่ความผิดต่อเนื่อง และหาใช่อายุความยังไม่เริ่มนับตราบใดที่จำเลยยังคงฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอยู่ไม่

ส่วนความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเริ่มเกิดเป็นความผิดขึ้นนับแต่วันที่ฝ่าฝืนไม่ยอมรื้อถอนอาคาร และเป็นความผิดต่อเนื่องตราบเท่าที่ยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ยอมรื้อถอนอาคาร เมื่อจำเลยยังฝ่าฝืนอยู่ตลอดมาอายุความจึงยังไม่เริ่มนับ

กรณีที่มีทั้งระวางโทษที่กำหนดและโทษรายวัน การที่จะพิจารณาว่าศาลใดลงโทษสูงต่ำกว่ากัน ต้องพิจารณาลักษณะของโทษแยกกัน

ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกและปรับ กับปรับรายวันวันละ 200 บาท จำเลยอุทธรณ์ฝ่ายเดียว และศาลอุทธรณ์ลงโทษปรับและปรับรายวันวันละ 500 บาท ย่อมเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย เมื่อโจทก์มิได้อุทธรณ์ขอให้เพิ่มโทษจำเลย จึงเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของอาคารและผู้ครอบครองอาคารได้จัดให้มีและดำเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อพักอาศัย โดยจำเลยก่อสร้างอาคารจำนวน 5 ชั้น ทั้งที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเพียง 4 ชั้น อันเป็นการผิดจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต และมีใช่เป็นการซ่อมแซมหรือดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง ต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบการกระทำผิด

ของจำเลยจึงได้มีคำสั่งให้จำเลยระงับการก่อสร้างชั้นที่ 5 ของอาคารดังกล่าว กับให้ รื้อถอนอาคารชั้นที่ 5 นั้นภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งและแจ้งให้จำเลย ทราบโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและปิดประกาศคำสั่ง ณ อาคารหรือ บริเวณที่มีการกระทำผิด และจำเลยทราบคำสั่งดังกล่าวโดยชอบแล้วตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 แต่จำเลยฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวโดยยัง ดำเนินการก่อสร้างอาคารชั้นที่ 5 ต่อไปตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2535 จนอาคาร ดังกล่าวก่อสร้างเสร็จเป็นอาคาร 5 ชั้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2535 รวมเป็นเวลา 12 วัน (ไม่รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์) อีกทั้งเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่รับคำ สั่งโดยชอบ จำเลยยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้จำเลยรื้อ ถอนชั้นที่ 5 ของอาคารข้างต้น และมีได้อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งแต่อย่างใด ซึ่ง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนับแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2535 จนถึงวันฟ้อง รวมเป็นเวลา 613 วัน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 40, 42, 66 ทวิ, 67, 71 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 11, 23, 24, 25 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 กับให้ปรับจำเลย นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนอาคารดังกล่าวเสร็จสิ้น

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 40, 42, 66 ทวิ, 67, 71 จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษเป็นรายกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐาน ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ระงับการก่อสร้าง จำคุก 4 เดือน และปรับ 40,000 บาท กับปรับรายวันตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนคำสั่งอีกวันละ 200 บาท เป็นเวลา 12 วัน เป็นเงิน 2,400 บาท ฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคาร จำคุก 4 เดือน และปรับ 40,000 บาท กับให้ปรับรายวันอีกวันละ 200 บาท นับแต่วันที่เริ่ม

ฝ่าฝืนคำสั่งจนถึงวันที่จำเลยรื้อถอนอาคารดังกล่าวเสร็จสิ้น โดยคำนวณวันที่เริ่ม
ฝ่าฝืนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 613 วัน คิดเป็นค่าปรับ 122,600 บาท รวมเป็นจำคุก 8
เดือน และปรับคำนวณถึงวันฟ้องเป็นเงิน 205,000 บาท โทษจำคุกจำเลยให้รอไว้มี
กำหนด 1 ปี หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 40, 42, 65, 67 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้
ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐาน
ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ระงับการก่อสร้าง ให้ลงโทษตามมาตรา 67 ปรับ
วันละ 500 บาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนรวมเป็นเวลา 12 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท
ฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคาร ให้ลงโทษตามมาตรา 65 วรรค
หนึ่ง ปรับ 5,000 บาท และให้ลงโทษตามมาตรา 65 วรรคสอง ปรับเป็นรายวันอีกวัน
ละ 500 บาท นับแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2535 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มฝ่าฝืนจนถึงวันฟ้องเป็น
เวลา 613 วัน เป็นเงิน 306,500 บาท กับให้ปรับอีกวันละ 500 บาท ตั้งแต่วันถัดจาก
วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนอาคารแล้วเสร็จ หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอสืบรับกันและมีได้โต้
เถียงกันว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตั้งฟ้อง จำเลยจัดให้มีการก่อสร้างอาคาร
เพื่อพักอาศัยจำนวน 5 ชั้น แต่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารจำนวน 4 ชั้น อัน
เป็นการผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับ

อนุญาตและมิใช่เป็นการซ่อมแซมหรือดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง ต่อมาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2535 เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งแจ้งให้จำเลยระงับการก่อสร้างอาคารชั้นที่ 5 และให้รื้อถอนอาคารชั้นที่ 5 ดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับคำสั่งคือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 แต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2535 จำเลยยังคงก่อสร้างอาคารชั้นที่ 5ต่อไปจนแล้วเสร็จในวันที่ 11 ธันวาคม 2535 เป็นเวลา 12 วัน และพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันทราบคำสั่งให้รื้อถอนอาคารคือวันที่ 26 ธันวาคม 2535 จำเลยก็ยังคงฝ่าฝืนไม่ยอมรื้อถอนอาคารนับถึงวันฟ้องเป็นเวลา 613 วัน เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยจัดให้มีการก่อสร้างอาคารที่ผิดรายการที่ได้รับอนุญาตซึ่งขัดต่อมาตรา 31 วรรคหนึ่ง และแม้จะฟังข้อเท็จจริงได้ดังที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยเข้าใจโดยสุจริตหรือสำคัญผิดว่าได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 5 ชั้นก็ตาม อาคารตามฟ้องก็ยังเป็นอาคารที่ผิดรายการที่ได้รับอนุญาตโดยไม่ต้องพิจารณาถึงเจตนาของผู้ดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้ชัดว่าแม้จำเลยจะมีผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ผิดรายการที่ได้รับอนุญาตแต่ได้รับโอนมาเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าว ก็ไม่สามารถทำให้จำเลยมีอำนาจดำเนินการก่อสร้างให้ผิดรายการที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้อีกหรือจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวให้พ้นจากภาระหน้าที่ในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนอาคารที่ผิดรายการที่ได้รับอนุญาตนั้นหาได้ไม่ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้จำเลยระงับการก่อสร้างอาคารและได้มีคำสั่งให้จำเลยรื้อถอนอาคารเพราะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ จึงเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนและถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย และการที่จำเลยผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารได้ฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ระงับการก่อสร้างอาคารและให้รื้อถอนอาคารด้วยการก่อสร้างอาคารต่อไปและงดเว้นไม่ยอมรื้อถอนอาคาร ย่อมถือได้ว่าจำเลยกระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันจำเลยประสงค์ต่อผลซึ่งเป็นการกระทำโดยเจตนา เป็นอันครบองค์ความผิดตามกฎหมาย แม้จำเลยจะอ้างว่าต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม

2537 เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้จำเลยดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามรายการตามเอกสารหมายเลข 3 ก็ตาม จำเลยก็ยังคงต้องรื้อถอนอาคารบางส่วน แต่จำเลยมิได้ดำเนินการรื้อถอนแต่อย่างใด หากยังคงฝ่าฝืนต่อไป กรณีเช่นนี้หาทำให้จำเลยพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดไม่ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (กฎหมายฉบับเดิม) มาตรา 40, 42, 65 และ 67 ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 นั้น ชอบหรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยจัดให้มีการก่อสร้างอาคารที่ผิดจากรายการที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 31 วรรคหนึ่งก็เป็นความผิดกรรมหนึ่ง ความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารเกิดขึ้นเมื่อจำเลยทราบคำสั่งแล้วกระทำการก่อสร้างต่อไปเป็นความผิดอีกกรรมหนึ่ง และความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเกิดขึ้นเมื่อจำเลยทราบคำสั่งแล้วดื้อไม่ยอมรื้อถอนอาคารภายในเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเป็นความผิดอีกกรรมหนึ่งโดยความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารและความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 และตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2535 ตามลำดับ ซึ่งเป็นวันเวลาที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ใช้บังคับแล้ว โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2535 เป็นต้นไปแม้การปรับบทกฎหมายลงโทษจำเลยนี้ คู่ความมิได้ฎีกาขึ้นมา แต่ก็ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้และเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง จึงให้ปรับบทลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 67 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา 40(1) และมาตรา 66 ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ประกอบมาตรา

มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง บัญญัติว่า "ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 30 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 40 มาตรา 44 หรือมาตรา 45 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง"

และมาตรา 66 ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง บัญญัติว่า "ผู้ใดมิได้รื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 42 โดยมีได้อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินสามหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น" บทกฎหมายดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความไว้ จึงต้องนำอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17 และกรณีคดีนี้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(4) กำหนดอายุความฟ้องร้องไว้ห้าปี ความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารเริ่มแต่วันที่จำเลยได้รับคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารแล้วไม่ปฏิบัติตามคำสั่งติดต่อกันไปจนถึงวันที่จำเลยดำเนินการก่อสร้างอาคารเสร็จกล่าวคือเริ่มแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2535 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2535 อายุความคือนับแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2535 หาใช่ความผิดต่อเนื่อง

อายุความยังไม่เริ่มนับตราใบที่จำเลยยังฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอยู่ดังที่ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่โจทก์ฟ้องคดีนี้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2537 จึงยังไม่เกิน กำหนดอายุความห้าปี และความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเริ่มเกิดเป็นความ ผิดขึ้นนับแต่วันที่ฝ่าฝืนไม่ยอมรื้อถอนอาคารคือตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2535 และ เป็นความผิดต่อเนื่องตราใบที่ยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ยอมรื้อถอนอาคาร ซึ่งปรากฏว่า จำเลยยังฝ่าฝืนอยู่ตลอดมาอายุความจึงยังไม่เริ่มนับ ดังนั้น คดีโจทก์ทั้งสองฐาน ความผิดจึงไม่ขาดอายุความ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยเกี่ยวกับการกำหนดโทษ เห็นว่า กรณีที่มีทั้งระวางโทษที่กำหนดและโทษรายวัน การที่จะพิจารณาว่าศาลใดลงโทษสูง ต่ำกว่ากัน ต้องพิจารณาลักษณะของโทษแยกกันดังจะเห็นได้จากกรณีถ้าพิจารณา โทษโดยรวมไม่แยกพิจารณาผลก็จะเป็นว่า ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกและปรับ กับปรับ รายวันวันละ 200 บาท ศาลอุทธรณ์ลงโทษปรับและปรับรายวันวันละ 500 บาท ศาล อุทธรณ์ลงโทษในสถานเบากว่า ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้และต้องลงโทษปรับรายวันนานหลาย ปี โทษปรับโดยรวมของศาลอุทธรณ์จะสูงกว่าศาลชั้นต้น จึงเห็นได้ว่าการแยก พิจารณาตามลักษณะของโทษน่าจะถูกต้อง ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษปรับรายวัน แก่จำเลยวันละ 500 บาทย่อมเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย โดยโจทก์มิได้ อุทธรณ์ขอให้เพิ่มโทษจำเลยจึงเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 212 จึงเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 67 วรรคสอง ประกอบมาตรา 40(1) และมาตรา 66 ทวิ วรรคหนึ่งและ วรรคสอง ประกอบมาตรา 42 เป็นความผิดหลายกรรมลงโทษทุกกรรมเป็นกระทง ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ลงโทษตามมาตรา 67 วรรคสอง ประกอบมาตรา 40(1) ปรับวันละ 200 บาท เป็นเวลา 12 วัน เป็นเงินค่าปรับ

2,400บาท ลงโทษตามมาตรา 66 ทวิ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 42 ปรับ 5,000 บาท และลงโทษตามมาตรา 66 ทวิ วรรคสอง ประกอบมาตรา 42 ปรับรายวันอีกวันละ 200 บาทนับแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2535 ถึงวันฟ้องเป็นเวลา 613 วัน เป็นเงินค่าปรับ 122,600บาท และปรับอีกวันละ 200 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะ รื้อถอนอาคารเสร็จนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมบัติ เดียววิศเรศ-จำลอง สุขศิริ-ไสว จันทะศรี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ